

1501206-77.2021.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDO BALDI MARCHETTI

Comarca: Valparaíso

Foro: Foro de Valparaíso

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 16/03/2022

... que o acusado é simples "mula" do tráfico e que foi induzido a erro. Alega que não se trata de pessoa voltada à prática delitiva. Afirma que o réu confessou o delito de favorecimento real e que deve ser reconhecido o erro de tipo em relação ao delito de tráfico de drogas. É o relatório. Fundamento e decido. Trata-se de ação penal visando apurar a prática dos crimes de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Valparaíso

1ª Vara

Rua Padre Mauro Eduardo s/nº, Centro, Valparaíso - 16880-000 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1501206-77.2021.8.26.0603

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2232062/2021 - DEL.POL.VALPARAISO, 19854876 -

DEL.POL.VALPARAISO, 2232062 - DEL.POL.VALPARAISO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDER JUNHO LUIZ DA SILVA

Defensor

188351/SP - Itamar Francisco Taveira de Souza

Vítima:

O Estado e outro

Aos 15 de março de 2022, às 16:30h, na sala de audiências da 1ª Vara do Foro de Valparaíso, Comarca de Valparaíso, Estado de São Paulo, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr. FERNANDO BALDI MARCHETTI, comigo Escrevente ao final nomeado, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Iniciados os trabalhos, presente o acusado Eder Junho Luiz da Silva, acompanhado de seu(ua) Defensor(a), o(a) Dr(a). Itamar Francisco Taveira de Souza, bem como o(a) representante do Ministério Público, o(a) Dr(a). Pierre Pena Rocha. Presente a(s) testemunha(s) Marcelo Rodrigo Pimentel e Carlos Chierigato. Os presentes concordaram que a audiência seja realizada de forma virtual. A Audiência é realizada excepcionalmente por meio virtual, diante da Pandemia do COVID-19 e da impossibilidade de acesso de pessoas ao prédio do fórum, ficando as partes cientes de que as gravações estarão armazenadas no próprio termo de audiência. A seguir, com a concordância das partes, o MM. Juiz iniciou a inquirição da(s) testemunha(s) arrolada(s), franqueando-se em seguida oportunidade de reperguntas às partes. A seguir, realizou-se o interrogatório. Na sequência,

pelas partes foi dito que não tinham diligências a serem requeridas nos termos do art. 403 do CPP. Por isso, pelo MM. Juiz foi dito: "Em não havendo mais provas a serem produzidas, declaro encerrada a fase de instrução probatória, passando-se aos debates". DADA A PALAVRA AO(A) Dr(a). PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA, ELE(A) ASSIM SE MANIFESTOU: "MM. Juiz. EDER JUNHO LUIZ DA SILVA foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, III, ambos da Lei 11.343/06, e no artigo 349-A, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, todos na forma do artigo 69, deste Diploma Legal. Encerrada a instrução, iniciaram-se os debates. Trata-se de processo regular, sem vícios ou nulidades, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação penal. O processo transcorreu seguindo o princípio do devido processo legal - formal e substancial - e sem qualquer vício a anulá-lo. A ação penal merece ser julgada PROCEDENTE para condenar EDER JUNHO LUIZ DA SILVA como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06, e no artigo 349-A, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, todos na forma do artigo 69, deste Diploma Legal. Encerrada a instrução criminal, apurou-se que EDER transportou e trouxe consigo o pacote contendo as drogas maconha, cocaína e os aparelhos celulares com a finalidade de adentrar a unidade prisional. EDER prestava serviços de entrega na unidade prisional com o caminhão da empresa RM Cadeiras, com objetivo de entregar estruturas metálicas para a confecção de cadeiras. Na portaria do presídio, agentes penitenciários iniciaram revista de praxe no referido caminhão. Nesse momento, notaram que EDER demonstrou certo nervosismo o que causou estranheza aos funcionários EDER saiu de forma ligeira do interior do caminhão e dirigiu-se ao banheiro do pavilhão de serviços. Assim que ele saiu do banheiro, o agente penitenciário Carlos Chierigato realizou uma revista no local e localizou um pacote. No interior do pacote foram encontrados um invólucro plástico contendo a droga maconha e outro invólucro plástico contendo a droga cocaína. Além disso, foram localizados três aparelhos celulares com carregadores. O banheiro em questão havia sido vistoriado antes de EDER utilizá-lo e nada de ilícito foi encontrado. EDER foi preso em flagrante delito e conduzido a Delegacia de Polícia de Valparaíso. Interrogado, EDER admitiu que dispensou o pacote apreendido no banheiro da unidade prisional (fls. 13/14). Dito isso, conclui-se que a autoria e a materialidade delitiva do delito apurado nestes autos restaram suficientemente comprovadas. A materialidade dos delitos apurados nestes autos está comprovada no boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudo de constatação prévia e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 114/117 e 118/121), e pela prova oral produzida durante o feito e, em especial, pelo conjunto probatório solidificado durante toda a persecutio criminis até o final de instrução processual. A autoria delitiva, igualmente, é inconteste e recai sobre o acusado. Os agentes de segurança que efetuaram a apreensão da droga e dos celulares são uníssomos em apontá-lo como autor dos fatos. Em juízo, o réu confessou parcialmente a prática delitiva. Alegou que não sabia que estava transportando entorpecente. A pessoa que lhe procurou, disse que havia apenas celulares dentro do pacote. Receberia a quantia de R\$ 3.000,00 pelo transporte. Porém, verifica-se que a alegação do réu não encontra respaldo probatório. Isso porque destoa das demais declarações colhidas. Verifica-se que a alegação do réu não passa de uma tentativa de se furtar da lei penal. Além disso, a versão exculpatória do acusado foi rechaçada pela prova oral colhida em juízo, que revelou toda a dinâmica dos fatos. Forçoso reconhecer, por oportuno, que os agentes penitenciários responsáveis pela apreensão da droga e dos celulares prestaram depoimentos coesos e harmônicos (na fase de inquérito e em juízo), em sintonia. O agente penitenciário Marcelo Rodrigo Pimentel prestou declarações corroborando os fatos descritos na inicial. Declarou que trabalhava como chefe de portaria. Constantemente determinada empresa levava material para confecção de cadeiras na penitenciária. Na data dos fatos, fizeram vistoria no caminhão. Em determinado momento, verificaram que o Eder, motorista do caminhão apresentou-se bastante nervoso e agitado. Diante disso, os agentes penitenciários ficaram mais atentos. Logo em seguida, Eder entrou no banheiro. Assim que ele saiu, um dos funcionários da penitenciária entrou no banheiro e localizou um pacote, em cujo interior havia celulares e entorpecente. Salientou que nenhum preso entrou no

banheiro depois disso. Do mesmo modo, informou que antes de Eder entrar no banheiro, o local foi vistoriado e não havia nada de ilícito no banheiro. Por fim, informou que Eder já era conhecido dos agentes penitenciários, por estar constantemente na penitenciária. Por isso, na data dos fatos, os agentes puderam perceber a mudança de comportamento do réu e que havia algo de errado. O agente Carlos Chierigato confirmou os fatos narrados por seu companheiro. Disse que Eder chegou com material para o trabalho dos detentos. Em revista na portaria, verificaram que o réu estava meio nervoso. Diante disso, a testemunha vistoriou o banheiro e não detectou nada. Ato contínuo, o réu passou para o lado do carona do caminhão e foi para o banheiro. Pelas condições do banheiro, a testemunha pode ver um movimento estranho por parte do acusado. Assim que o réu saiu do banheiro, a testemunha fez nova vistoria e localizou um pacote, o qual foi entregue à Diretoria. Posteriormente soube que havia celulares, maconha e cocaína. Por fim, informou que, entre sua vistoria e a ida do Eder ao banheiro, ninguém utilizou o local. Do mesmo modo, após a saída de Eder do banheiro, ninguém mais entrou no local. Assim, o contexto no qual os fatos ocorreram deixou claro a prática dos delitos pelos quais o réu foi denunciado. Os agentes de segurança narraram com coesão a dinâmica dos fatos. Por conseguinte, o conjunto probatório coligido, sob o crivo do contraditório, é absolutamente eficiente para condenar o acusado, mormente porque robustecido por informes do inquérito policial, constituindo, pois, firmes elementos para convencimento do Juízo. O crime restou comprovado e se deu nos estritos limites enunciados na denúncia. Por fim, de importância ímpar ainda ressaltar que o testemunho dos agentes de segurança tem plena credibilidade, assim como qualquer outra testemunha compromissada. Não há qualquer distinção no valor probatório do testemunho prestado por agentes da segurança pública estatal. A condição profissional dos agentes não pode subtrair crédito ao seu testemunho, aliás, pelo contrário, eles não só gozam da presunção de veracidade genericamente atribuída (como regra) a todos os cidadãos, como têm sua seriedade reforçada pelo fato de serem agentes públicos, situação que tem a idoneidade como pressuposto. Do mesmo modo, restou configurada a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, III, da Lei 11.343/06, na medida em que o delito foi praticado nas dependências de unidade prisional e visava a entrega dos entorpecentes a pessoas que estavam cumprindo pena na Penitenciária. Por fim, o delito previsto no artigo 349-A ficou apenas na esfera da tentativa, uma vez que o acusado não conseguiu ingressar com os objetos na unidade prisional, por circunstâncias alheias à sua vontade. Diante das circunstâncias do feito, restou tipificado os delitos em espécie. Feitas estas considerações, medida de rigor é a condenação de EDER JUNHO LUIZ DA SILVA como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06, e no artigo 349-A, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, todos na forma do artigo 69, deste Diploma Legal. Dosimetria da Pena Na primeira fase, verifica-se que a pena deve ser aplicada no mínimo legal, considerando inexistirem circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado. Na segunda fase não há agravantes ou atenuantes a serem reconhecidas. Na terceira fase, deve ser aplicada a causa de aumento prevista no artigo 40, III, da Lei 11.343/06, uma vez que o crime foi praticado no interior de unidade prisional e visava atingir pessoas que estavam cumprindo pena. No que tange à causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, tem-se que tal benefício não pode ser reconhecido, pois o réu, apesar de ser primário, trouxe consigo quantidade considerável de entorpecente (303g de maconha e 389g de cocaína). Por ser circunstância preponderante, a quantidade de entorpecente deve ser levada em consideração pelo magistrado no momento da dosimetria da pena. Além disso, a quantidade de droga apreendida revela que o réu está inserido em práticas criminosas. Por outro lado, em relação ao crime previsto no artigo 349-A, do Código Penal, deve ser aplicada a redução, em virtude da tentativa (artigo 14, II, do Código Penal). Por fim, considerando se tratar de concurso material de delitos, as penas devem ser somadas, nos termos do artigo 69, do Código Penal. Tendo em vista a gravidade dos delitos e que o crime de tráfico de drogas é equiparado aos crimes hediondos, o regime inicial de cumprimento de pena deverá ser o fechado, em obediência ao estabelecido no artigo 2º, §1º, da Lei 8.072/90. Por fim, impossível

a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, porquanto ausentes os requisitos legais. Ademais, tal benefício é incompatível com as finalidades propostas pela lei de crimes hediondos. Feitas estas considerações, requeiro a procedência da ação penal, nos termos formulados na denúncia, e a consequente CONDENAÇÃO do réu EDER JUNHO LUIZ DA SILVA como incurso no artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06, e no artigo 349-A, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, todos na forma do artigo 69, deste Diploma Legal, fixando a pena nos termos acima dispostos. DADA A PALAVRA AO(À) Dr(a). DEFENSOR(A), ELE(A) ASSIM SE MANIFESTOU: Inicialmente cumpre salientar que ficou claro que o acusado colaborou com a justiça ao declarar toda a prática criminosa nos mínimos detalhes, assumindo a responsabilidade dos seus atos. Por outro lado, temos que dar o voto de confiança por ter assim procedido e ficou claro e evidente que foi "aliciado" ou seja serviu de "mula" pelos verdadeiros traficantes levando-o ao erro, pois a proposta era que não teria problemas porque no pacote entregue teria apenas celulares e carregadores. Colaborou ainda mais com a justiça. Sem falar que a partir do momento que delatou os verdadeiros traficantes, corre risco de morte estando encarcerado. Em que pese a gravidade do crime de drogas, como já dito, foi aliciado e levado a erro, tudo por sua inocência pois é um praticamente analfabeto, além de pouco estudo é matuto na simplicidade. Sua vida pregressa é "in albis" nunca foi processado, é primário e de bons antecedentes. Tem uma filha para criar e sustentar, que esta na presença da tia na falta do pai. O pacote entregue a ele já veio acondicionado de uma forma que ele não conseguia visualizar o que tinha em seu interior. Da forma que ele pegou na segunda feira levou para o interior da penitenciária, e por uma fraqueza e deslize aceitou a proposta de aliciamento. Os agentes que estão acostumados a vê-lo notou a diferença no momento em que ele desceu do caminhão. Sabe o porquê disso? Simplicidade. Nunca tinha feito uma "loucura" dessa, foi fácil identificar o nervosismo da primeira vez. Isso tudo por que do ponto de vista dele no "pacote" só tinha carregadores e celular. Senão vejamos o um trecho do depoimento do Agente. Fls. 09. Termo de depoimento do agente: "...mas notei que o senhor Eder Junho Luiz da Silva demonstrou um certo nervosismo, que nunca havia percebido em ocasiões anteriores..." (GRIFAMOS) Tá claro e evidente a simplicidade e a falta de malícia do acusado, que a nosso ver não pode ser penalizado por um crime que jamais imaginaria de cometer. Errou no momento que aceitou o "pacote" a troco de valores, mas o que não imaginava era o conteúdo daquele pacote. Se fosse uma pessoa maliciosa teria aberto o pacote e retirado a droga e levado somente os celulares e carregadores, que era o que o acusado havia se proposto a fazer. Outro indicativo de que ele não faz parte do mundo do crime é a varredura que foi feita no seu celular e nada foi encontrado, conforme relatório da investigação as fls. 149, o que mais uma vez colaborou com as investigações fornecendo a senha. Segue abaixo, parte do relatório. Se vê que ele quem forneceu a senha e nada de ilícito foi encontrado. Óbvio não faz parte do mundo do crime ou de qualquer organização criminosa. Não bastasse temos a confissão, o arrependimento e a colaboração do acusado quando ao crime ocorrido. Desde o relato na penitenciária, quanto o relato na DelPol de Valparaíso e hoje em juízo, foram todos congruentes e verdadeiros. Estamos diante do ERRO DE TIPO PERMISSIVO, pois segundo a melhor doutrina entende-se por erro de tipo permissivo a falsa percepção sobre a situação de fato. Já o erro de permissão, por sua vez, tem como escopo uma descriminante naquilo que tange a sua existência ou referente aos seus limites de autorização e legitimidade. Não existia dolo na conduta do acusado no que se refere a droga, pois quiçá sabia da sua existência. Erro de tipo é a falsa percepção da realidade acerca dos elementos constitutivos do tipo penal. Extraí-se essa conclusão do art. 20, caput, do CP, que somente menciona as elementares. É o chamado erro de tipo essencial. Somando a forma que o pacote foi entregue (sem visualização), a inocência, a falta de malícia criminal, o semi-analfabetismo e a simplicidade do acusado, resultou ao erro. A nosso ver, o acusado merece responder pelo artigo 349-A, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Pois a sua conduta se amolda a essa tipificação. Caso seja ultrapassada o erro de tipo para que seja excluída a tipificação da denúncia quanto ao tráfico, o que se aplicaria por todas as condições pessoais e

subjetivas do acusado seria a causa de diminuição de pena. Ao olhar o acusado e ouvi-lo é nítida a simplicidade e tudo mais o que já foi dito acima das suas condições pessoais e pretéritas, sendo assim, é evidente que a causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º da lei de drogas, deve ser aplicado em seu grau máximo. O acusado é um trabalhador por toda uma vida e cometeu um erro, mas não integra a qualquer facção criminosa ou organização criminosa. Ficou claro na vistoria do celular. Por fim em audiência as testemunhas confirmaram a versão do acusado de que não era possível saber o que tinha no pacote. Por todos estas razões fáticas e de direito, requer a VOSSA EXCELENCIA, seja o ACUSADO CONDENADO no artigo 349-A, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, substituindo a pena por restritiva de direito. E, seja ABSOLVIDO PELO ERRO DE TIPO no que se refere ao crime de drogas. Caso seja ultrapassado, e Vossa Excelência entender que o acusado praticou o crime de tráfico, que a pena seja diminuída em grau máximo conforme prevê o artigo 33, §4º da lei de drogas, substituindo a pena de reclusão por uma restritiva de direito. Para tanto, em ambos as decisões, necessária a LIBERDADE ACUSADO, expedindo assim o competente ALVARÁ DE SOLTURA. A seguir, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. EDER JUNHO LUIZ DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06 e no artigo 349-A, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, todos na forma do artigo 69, do Código Penal, porque, no dia 25 de agosto de 2021, por volta das 10h30min, no Centro de Progressão Penitenciária de Valparaíso, neste município e comarca, transportou e trouxe consigo, com a finalidade de posterior entrega a consumo e fornecimento a terceiros (tráfico), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 01 (um) invólucro plástico contendo a droga conhecida por "maconha", com massa líquida de 303,99 gramas e 01 (um) invólucro plástico contendo a droga cocaína, com massa líquida de 389,74 gramas; bem como, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, tentou ingressar com 03 (três) aparelhos celulares, das marcas Xiaomi e Samsung, acompanhados dos carregadores, no referido estabelecimento prisional. Folhas de antecedentes e certidões criminais (fls. 38, 39, 40, 97/98, 106 e 111/113). Foi determinada a notificação do acusado para oferecimento de defesa prévia (fls. 94). Regularmente notificado (fls. 132), o acusado ofereceu defesa prévia (fls. 138/141). A denúncia foi recebida e o réu foi citado. Durante o curso da instrução foi tomado o depoimento das testemunhas arroladas pelo Ministério Público. O réu foi regularmente interrogado. Em sede de alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal, nos moldes da denúncia, diante da comprovação da autoria e materialidade delitivas. A combativa Defesa aduziu que o acusado é simples "mula" do tráfico e que foi induzido a erro. Alega que não se trata de pessoa voltada à prática delitiva. Afirma que o réu confessou o delito de favorecimento real e que deve ser reconhecido o erro de tipo em relação ao delito de tráfico de drogas. É o relatório. Fundamento e decido. Trata-se de ação penal visando apurar a prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e favorecimento real. A ação penal é procedente. No âmbito da materialidade, a prova é constituída pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 01/02); boletim de ocorrência (fls. 03/08); auto de exibição e apreensão (fls. 10); laudo de constatação prévia de entorpecente (fls. 23/25 e 26/28); e laudo definitivo de exame químico-toxicológico (fls. 81/83, 114/117; 118/121; 146/148); e, em conformidade com o disposto no artigo 167, do Código de Processo Penal, pela prova oral produzida. Tocante à autoria, certo é que o réu disse que sabia apenas da existência dos celulares e que receberia dinheiro para leva-los até o presídio. Negou que tivesse conhecimento do entorpecente. Não obstante o relato do acusado, a prova oral colhida sob o crivo do contraditório confirma a autoria delitiva. O agente penitenciário Marcelo Rodrigo Pimentel disse na fase administrativa que: "prestava serviços no setor de portaria, e por volta das 10:30 h, chegou o caminhão da empresa RM Cadeiras, para entregar estruturas metálicas para a confecção de cadeiras neste CPP, momento este em que iniciei a revista de praxe juntamente com o servidor Fábio Antonio de Jesus no referido caminhão para que adentrasse na unidade, mas notei que o motorista o senhor Eder Junho Luiz da Silva demonstrou um certo nervosismo, que nunca havia percebido em ocasiões anteriores. Nesse momento em razão do estado emocional do

motorista, comuniquei os servidores Antonio Emerson Fernandes Melo Pereira (Diretor do Núcleo de Segurança do Turno I-substituto) e Carlos Chierigato (responsável pelo Pavilhão de serviços), para que me auxiliasse com término da revista no local de descarga, momento este que o senhor Eder saiu do interior do caminhão ligeiramente, dirigindo-se até o banheiro do Pavilhão de serviços, e assim que o senhor Eder saiu do banheiro, o funcionário Carlos Chierigato realizou uma revista no local, e encontrou um pacote contendo os ilícitos descritos acima. Informo ainda que o banheiro do setor de Pavilhão de serviços foi revistado antes do motorista Eder usá-lo, e não foi encontrado nenhum ilícito, constatando assim que quem deixou os materiais ilícitos foi o motorista Eder. Por fim, repassei as informações e entreguei as apreensões a esta diretoria para que fossem tomadas as providências cabíveis.". Em juízo corroborou a versão anteriormente exposta. No mesmo sentido o depoimento do agente penitenciário Carlos Chierigato em juízo. Tais testemunhos autorizam o reconhecimento da autoria e materialidade delitivas, anotando-se que as palavras das testemunhas se revestem de coerência, robustez e segurança e não demonstram qualquer tendência para o exagero ou falsidade, devendo ser aceitas como elementos hábeis à condenação, suportando o acusado, então, o ônus de contrastá-las, o que não fez. Não se pode presumir que a ação do agente penitenciário, investido pelo Estado em função de vigilância, tenha por destinação a incriminação de um cidadão inocente. Seria preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a respeito. E a prova colhida não revela qualquer traço de irregularidade na conduta dos agentes penitenciários. Ademais, tem-se que o conjunto probatório amealhado permite concluir que a finalidade do entorpecente seria a entrega a consumo de terceiros, a confirmar o teor da imputação contida na denúncia. Com efeito, várias circunstâncias, devidamente demonstradas, conspiram para a formação de convicção no sentido da destinação mercantil da droga apreendida: (a) a natureza, quantidade e variedade da droga; (b) forma de acondicionamento do entorpecente; e (c) forma com que se deu a prisão do réu. Como se sabe, o tipo penal incriminador à espécie se integra de várias fases sucessivas, articuladas uma com as outras, variando desde a produção até a sua entrega ao consumo, com atos preparatórios, acessórios ou complementares, alguns até despidos do caráter de comércio. Sendo impossível apurar em conjunto a sua integralidade, há de se ponderar todas as fases em que se desenvolve esta atividade, tendo a lei se contentado, no escopo de combater as toxicomanias, em admitir que qualquer uma delas, por si só, configura o crime de tráfico ilícito de drogas. Além do mais, traficante "não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que de algum modo participa da produção e na circulação de drogas" (RF 320/237). Não há evidências, ademais, de que a droga estivesse com o acusado apenas para uso próprio. Nem mesmo a alegação de vício tem o condão de operar a desclassificação para uso, pois como de trivial sabença, normalmente encontra-se em uma mesma pessoa as figuras de usuário e traficante, sem que com isso saia ileso do crime de maior gravidade. Também restou demonstrada a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, uma vez que o réu praticou o delito previsto no artigo 33, da citada lei, nas dependências de estabelecimento prisional. Tratando-se de réu primário, com bons antecedentes, sem indícios que se dedique à atividade criminosa ou integre organização criminosa, de rigor a aplicação da causa redutora prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. Nesse ínterim, conforme preleciona Guilherme de Souza Nucci ao comentar o supracitado dispositivo: "O legislador não estipulou quais seriam, apenas mencionando dever o magistrado reduzir a pena de um sexto a dois terços. Cremos que, como sempre, deve o julgador pautar-se pelos elementos do art. 59, do Código Penal, com a especial atenção lançada pelo art. 42 desta Lei" (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 5ª Ed., RT, 2010, p. 372/373). Desta feita, tendo em vista serem as circunstâncias judiciais favoráveis ao réu e a quantidade relativamente pequena de entorpecente apreendida, a reprimenda deve ser diminuída no montante de 2/3 (dois terços). Pouco crível a versão exculpatória no sentido de que desconhecia a existência do entorpecente, vez que diante da promessa de recebimento de elevada quantia em dinheiro, o acusado teria plenas condições de desconfiar da existência do entorpecente apreendido. Destarte, a tese de atipicidade da conduta por erro de

tipo não comporta acolhimento vez que estão ausentes os contornos da propalada excludente de ilicitude, ante a não existência de qualquer elemento apto a demonstrar que o réu desconhecia a natureza proscrita da substância apreendida. No tocante ao delito de favorecimento real, restou de demonstrado, de forma incontestada, que, nas condições de tempo e lugar descritas na denúncia, o acusado tentou ingressar no estabelecimento prisional desta Comarca portando aparelho celular. Consuma-se o crime de favorecimento real, descrito no art. 349-A do Código Penal, com o efetivo ingresso do aparelho celular no estabelecimento prisional, não sendo necessário que seja também tal aparelho utilizado pelo preso para restar caracterizado o dolo. No caso em apreço, verifica-se que o acusado tentou entrar na penitenciária com os aparelhos celulares (fato este descrito na denúncia), mas não logrou êxito, já que a consumação foi impedida pela atuação do agente penitenciário. Destarte, a prática da conduta do crime de favorecimento real (artigo 349-A do Código Penal) não se consumou, sendo de rigor o reconhecimento da modalidade tentada. Inviável, portanto, a absolvição, vez que a prova é francamente hostil ao acusado. Demonstradas a autoria e a materialidade, passo a dosar a pena a ser aplicada ao réu. Na primeira fase, bem sopesados os elementos norteadores do artigo 59, do Código Penal, cumpre reconhecer que o réu agiu com dolo normal para a espécie e não ostenta antecedentes desabonadores, nos termos da Súmula 444, do C. Superior Tribunal de Justiça. Não por outra razão, a pena deve ser fixada em seu patamar mínimo, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa para o crime de tráfico e 03 (três) meses de detenção para o delito de favorecimento real. Na segunda fase, em que pese a confissão em relação ao delito de favorecimento real, incabível a fixação da pena em patamar inferior ao mínimo abstratamente previsto, conforme Súmula nº 231, do C. Superior Tribunal de Justiça. Na terceira fase, no tocante ao crime de tráfico exaspero a pena em 1/6 (sexto), diante da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, totalizando 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Ainda quanto ao delito de tráfico, em observância ao disposto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, reduzo 2/3 da pena, perfazendo 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa. Ainda na terceira fase, reconhecida a tentativa do crime de favorecimento real, a partir do critério que se infere no parágrafo único, do artigo 14, do código Penal (proximidade da consumação), diminui-se 1/3 (um terço) da pena, porquanto a agente percorreu parte considerável do iter criminis, aproximando-se, por demais, da consumação, totalizando 02 (dois) meses de detenção. Derradeiramente, em obediência ao disposto no artigo 33, §3º, do Código Penal, anote-se que a pena carcerária deverá ser cumprida em regime inicial aberto. Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal movida pela Justiça Pública e, em consequência, CONDENO o acusado EDER JUNHO LUIZ DA SILVA, qualificado nos autos, à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial aberto, e ao pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, de valor unitário mínimo, por infração ao disposto no artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06; e à pena de 02 (dois) meses de detenção, no regime inicial aberto, por incurso no artigo 349-A, na forma do artigo 349-A, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Nos termos do artigo 44 do Estatuto Repressivo, vislumbro que a substituição da pena privativa de liberdade é socialmente recomendável. Desta feita, substituo a pena corporal por 02 (duas) restritivas de direitos, sendo a primeira prestação pecuniária consistente na entrega de 01 (uma) cesta básica de alimentos para entidade assistencial determinada pelo Juízo da Execução Penal, e a segunda consistente no pagamento de um salário mínimo, também para uma entidade assistencial desta Comarca, a ser determinada pelo Juízo da Execução Penal. O réu poderá apelar em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso, pois não restaram caracterizados os motivos que indiquem a necessidade de custódia cautelar, conforme artigo 312, do Código de Processo Penal. Expeça-se alvará de soltura clausulado. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome dos réus no rol dos culpados, e oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis. Custas na forma da lei. Publique-se.

Intime-se. Cumpra-se. ----- Certifico, por fim, que a(s) testemunha(s) permaneceu(ram) incomunicável(is) e em sala própria antes do(s) seu(s) depoimento(s). Nada mais havendo foi encerrado o presente que lido e achado conforme, segue devidamente assinado. Eu, _____, Rosely da Cunha, Escrevente, digitei e subscrevi.

MM. Juiz: